

1500296-28.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... alegou que já foi internado na Fundação Casa por tráfico de drogas. Negou que portasse qualquer bolsa. Era apenas "olheiro". Sabia que os outros estavam no tráfico ilícito de drogas. Iria ganhar cem reais por dia. O menor e o que correu iriam pagá-lo, ou seja, Pablo e Gabriel. Não tinha drogas consigo, era tudo do adolescente. Na casa do adolescente os guardas apreenderam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19) 3372-

3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500296-28.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2055696/2022 - 05º D.P. PIRACICABA, 23275074 - 05º D.P. PIRACICABA, 252/22/528 -

05º D.P. PIRACICABA, 2055696 - 04º D.P. PIRACICABA, 252/22/528 - 04º D.P.

PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MIQUEIAS MARQUES

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 27 dias do mês de junho de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Paulo Kishi e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) LUCAS MIQUEIAS MARQUES, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Francisco Dernival Miranda Júnior, Juvenal Estevão de Macedo.

Ausente a testemunha Pablo Luan Bidias Portella, o qual foi devidamente intimado através de sua genitora, conforme certidão de fls.180.

Solicitada informação junto à Serli Miyoko Sato, diretora do Cartório da Vara da Infância e da Juventude, obtivemos a informação de que referido adolescente encontra-se custodiado na Fundação Casa - Unidade Rio Piracicaba, conforme

documento juntado aos autos a fls.183.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Francisco e Juvenal) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s).

Pelas partes foi dito que desistem da oitiva da testemunha Pablo Luan Bidias Portella.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação à testemunha Pablo Luan Bidias Portella.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza,

LUCAS MIQUEIAS MARQUES está sendo processado pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta de 10h47m, na rua das Sapucaias, nº 1, bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca, envolveu o adolescente Pablo Luan Bidias Portella na conduta criminosa e com ele agindo com unidade de desígnios, trazia consigo 140 porções de "cocaína", 90 porções de "crack" e 29 porções de "maconha", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Outrossim, porque, no dia 25 de fevereiro de 2022, após 10h47m, na rua Francisco Maiolino, nº 58, bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca, guardava e/ou mantinha em depósito 74 porções de cocaína, 52 porções de "crack" e 26 porções de "maconha", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, outrossim, que no mesmo dia, após 10:47 h, na rua dos Mognos, 124, Bosques do Lenheiro, nesta cidade e comarca, o infrator Pablo Luan guardava ou tinha em depósito 155 porções de "crack" destinadas à mercancia ilícita, sem autorização. Os fatos imputados na exordial acusatória foram comprovados ao longo da instrução criminal, pelo que a ação é procedente.

A materialidade foi comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), Laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 153/157).

A autoria, da mesma forma, é indubitosa.

Segundo se apurou, guardas civis passavam pelo local, quando avistaram "três indivíduos em atitude suspeita", ocasião em que um deles (não identificado) entregou uma bolsa para o denunciado LUCAS. Ao perceberem a aproximação, os indivíduos empreenderam fuga, sendo que aquele que entregou a bolsa não foi identificado e logrou evasão.

Ato contínuo, durante a fuga o denunciado entregou ao referido adolescente a bolsa que trazia consigo, o que foi presenciado pelos guardas civis. Feita abordagem, na bolsa entregue pelo denunciado ao adolescente foram encontradas 140 porções de "cocaína", 90 porções de "crack" e 29 porções de "maconha", além da quantia de R\$ 82,00. Neste momento, o denunciado disse ao adolescente "Segure os B0's... É tudo seu", o que foi ouvido pelos guardas civis.

Em continuidade, diante do apurado até então, os guardas dirigiram-se às residências do denunciado e do infrator. Na residência do adolescente Pablo foram encontradas 155 porções de "crack". Por sua vez, na residência do denunciado foram localizadas mais 74 porções de cocaína, 52 porções de "crack", 26 porções de maconha, uma balança de precisão e rolos plásticos, usados para o embalo de entorpecentes.

Perante a autoridade policial, o adolescente disse que era responsável pelo tráfico ilícito. Por sua vez, o denunciado alegou que o responsável era o adolescente e que ele apenas agia como "olheiro".

Diante das circunstâncias apuradas, local da prisão, apreensão de significativa quantidade e variedade de porções individualizadas, petrechos para o embalo de drogas e dinheiro, indubitável que a droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas.

Com efeito, a testemunha Francisco Dernival Miranda Junior, guarda civil, narrou "na data de hoje estava de serviço com os guardas William e Macedo realizando patrulhamento pelo Bosque dos Lenheiros e avistamos três indivíduos em atitudes suspeitas, sendo possível observar que um deles levava consigo uma bolsa tipo "tira-colo" e este entregou algum objeto para o outro rapaz e recebeu algo em troca colocando no interior da referida bolsa, sendo assim resolvemos abordá-los, contudo, um deles percebendo que seriam investigados avisou os demais, o rapaz que momento antes recebeu o objeto deixou o local e foi seguido pelo guarda Macedo, contudo, acabou não sendo mais localizado, enquanto os outros dois também tentaram fugir do local, porém, foram seguidos por minha pessoa e presenciei quando um dos indivíduos entregou a bolsa para o outro e acabei alcançando e abordando este último e o guarda William logrou abordar o terceiro indivíduo. Que o rapaz abordado por minha pessoa em poder da bolsa foi identificado como sendo o adolescente Pablo Luan Bidias Portella e no interior da citada bolsa foram encontrados 140 porções de cocaína, 90 porções de "crack" 29 porções de maconha e a quantia de R\$ 82.00; Que o indivíduo abordado pelo guarda William, identificado como Lucas Miqueias Marques nada de ilícito foi encontrado; Que o adolescente foi conduzido até o local onde estavam Lucas e o guarda William e neste momento Lucas se dirigiu para o adolescente dizendo ; "... segure os bos, é tudo seu..."; Que dando continuidade nas diligências nos deslocamos até a residência do adolescente Pablo, onde sua mãe autorizou nosso ingresso no imóvel e foram encontradas 155 pedras de "crack" na sala da residência escondidas dentro de uma bota atrás de um móvel, nos deslocamos também até a residência de Lucas, onde fomos atendidos pelo sr. João Luiz Pereira, avô do mesmo, o qual autorizou a entrada e acompanhou a vistoria e no quarto de Lucas foram localizados 74 porções de cocaína, 52 pedras de "crack", 26 porções de maconha, uma balança de precisão e rolos de "papel film"; Que o avô de Lucas não acompanhou a ocorrência tendo em vista que recebeu uma ligação do hospital e não pode comparecer" (fls. 03/04).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento prestado na fase policial. O réu mandava o adolescente "segurar o b.o. (boletim de ocorrência). Não conhecia o réu ou o adolescente.

No mesmo sentido o guarda civil Juvenal Estevão de Macedo que asseverou "na data de hoje, juntamente com minha equipe de guardas civis, dentre eles Miranda e William fazíamos patrulhamento pelo bairro Bosque dos Lenheiros, nesta cidade e o visualizamos três indivíduos em atitudes suspeitas, sendo possível constatar que um deles levava consigo uma bolsa tipo "tira-colo" e o mesmo entregou algum objeto para o outro rapaz , recebendo algo e colocando no interior da bolsa, desta forma decidimos abordá-los, contudo, um deles percebendo que seriam abordados acabou avisando os outros dois; O mesmo indivíduo, que, momentos antes, recebeu o objeto deixou o local e foi seguido por minha pessoa, contudo, logrou êxito em fugir, enquanto os outros dois também tentaram fugir do local, porém, foram seguidos pelos guardas Miranda e William. que o rapaz abordado pelo GM Miranda leva a consigo uma bolsa e foi identificado como sendo o adolescente Pablo Luan Bidias Portella e no interior da citada bolsa foram encontrados 140 porções de cocaína, 90 porções de "crack" 29 porções de maconha e a quantia de R\$82.00; que o indivíduo abordado pelo guarda William, identificado como Lucas Miquéias Marques nada de ilícito foi encontrado; Que o adolescente foi conduzido até o local onde estavam Lucas e o guarda William e neste momento Lucas se dirigiu para o adolescente dizendo ; "... segure os bos, é tudo seu..."; que dando continuidade nas diligências nos deslocamos até a residência do adolescente Pablo, onde sua mãe autorizou nosso ingresso no imóvel e foram encontradas 155 pedras de "crack" na sala da residência escondidas dentro de uma bota atrás de um imóvel, nos deslocamos também até a

residência de Lucas, onde fomos atendidos pelo sr. João Luiz pereira, avô do mesmo, o qual autorizou a entrada e acompanhou a vistoria e no quarto de Lucas foram localizados 74 porções de cocaína, 52 pedras de "crack", 26 porções de maconha, uma balança de precisão e rolos de "papel film"; que o avô de Lucas não acompanhou a ocorrência tendo em vista que recebeu uma ligação do hospital e não pode comparecer; que foi dado voz de prisão à Lucas e ambos autores foram conduzidos até esta delegacia de polícia" (fls. 05).

Em juízo ratificou integralmente o depoimento colhido na fase policial. Inclusive confessaram que estavam comercializando juntos (réu e adolescente). Não conhecia nenhum dos dois.

O adolescente Pablo Luan Bidias Portella declarou "Na data de hoje estava no local em companhia de Lucas, contudo era eu que estava traficando; que na bolsa tinha aproximadamente 1.400 porções de "crack", 280 porções de maconha e 1.300 porções de "óleo" e a quantia aproximada de R\$ 60,00, que tais drogas eram de minha propriedade; que os guardas foram até minha residência, onde localizaram outra quantidade de drogas" (fls. 06).

Perante a autoridade policial, o réu alegou "Na data de hoje estava no local, juntamente com Pablo, o qual estava vendendo drogas e eu estava apenas fazendo a função de "olheiro"; que as drogas e o dinheiro localizados na bolsa pertenciam à Pablo. Que em minha residência foi localizada apenas uma balança e dois rolos de papel film; Que o guarda Miranda acabou me agredindo batendo com a arma na minha barriga".(fls. 07).

Interrogado em juízo, alegou que já foi internado na Fundação Casa por tráfico de drogas. Negou que portasse qualquer bolsa. Era apenas "olheiro". Sabia que os outros estavam no tráfico ilícito de drogas. Iria ganhar cem reais por dia. O menor e o que correu iriam pagá-lo, ou seja, Pablo e Gabriel. Não tinha drogas consigo, era tudo do adolescente. Na casa do adolescente os guardas apreenderam mais droga. Na sua casa apreenderam uma balança quebrada. Na delegacia foi acusado que a droga lhe pertencia. Nada tem contra os guardas civis.

Diante do apurado há provas suficientes que demonstram a procedência da imputação. A narrativa dos guardas foi contundente e uníssona em confirmar que passavam pelo local, quando avistaram e suspeitaram do réu que estava com o adolescente e mais terceiro indivíduo não identificado, sendo que, ao perceberem a aproximação, o terceiro entregou algo para LUCAS e evadiu-se. O réu e o adolescente também empreenderam fuga. Durante a evasão, ao perceber que seria detido, o réu entregou a bolsa que trazia consigo ao adolescente e lhe disse que ele deveria "segurar o b.o", o que foi ouvido pelos guardas civis. Durante a abordagem, os policiais verificaram que na bolsa entregue havia 140 porções de "cocaína", 90 porções de "crack" e 29 porções de "maconha", além da quantia de R\$ 82,00. Outrossim, foram realizadas diligências na residência de Lucas e do adolescente. Na residência de LUCAS foram localizadas 74 porções de cocaína, 52 porções de "crack", 26 porções de maconha. Outrossim, na residência do adolescente foram localizadas 155 porções de "crack".

Assim, não há dúvidas que o entorpecente descrito na inicial foi pertencia ao réu e destinava-se ao crime em questão.

Primeiro, porque, o terceiro lhe entregou imediatamente a bolsa, o que deixa claro que ele era o responsável pelo entorpecente. Outrossim, na residência do réu foram localizadas mais 74 porções de cocaína, 52 porções de crack e 26 de maconha, mesmas substâncias localizadas em seu poder.

Portanto, as circunstâncias apuradas demonstram que ele era o responsável pela droga e envolveu o adolescente em sua empreitada criminosa, conduta usual de traficantes, com o fim de livrarem-se de suas responsabilidades.

Pertinente salientar que não há nada que invalide os depoimentos dos guardas civis, devendo ser valorados como as demais provas do processo.

Neste sentido:

APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06.

Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Valor do depoimento testemunhal de servidores policiais que, ratificados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia

probatória. Inexistência de contradições ou elementos de convicção que possam retirar-lhe a credibilidade. Dosimetria da pena mantida. Regime inicial fechado adequadamente imposto. Análise da detração que compete ao Juízo das Execuções Criminais. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação nº 3005429- 53.2013.8.26.0320, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Camargo Aranha Filho, j .05/05/2016) – Grifo nosso A alegação do adolescente de que ele seria o responsável pela droga e não o réu não é crível. Como dito alhures, muitos traficantes envolvem adolescentes no crime para livrarem-se de eventual responsabilidade, ficando aos menores a responsabilidade pelo delito.

Portanto, tendo em vista que a bolsa foi entregue diretamente ao réu, na casa dele foi encontrada droga da mesma espécie e o fato do réu evadir-se do local, inequívoco que a droga lhe pertencia.

Outrossim, a quantidade e variedade de droga apreendida demonstram que o entorpecente destinava-se à mercancia ilícita.

Portanto, imperiosa a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de drogas.

Passo a analisar a dosimetria da pena.

Na primeira-fase a pena deve ser fixada acima do mínimo legal diante da considerável quantidade e variedade de droga apreendida e respectiva natureza, conforme dispõe o artigo 42, da Lei de Drogas.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. O réu negou que a droga lhe pertencesse e tentou atribuí-la ao adolescente, o que não pode ser visto como confissão.

A quantidade e variedade de entorpecente apreendida demonstram que o réu dedicava-se ao crime imputado na inicial. Além disso, o réu ostenta atos infracionais, inclusive pelo delito assemelhado ao tráfico de drogas, razão pela qual deve ser afastada a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.

Ainda que os atos infracionais não possam ser considerados para apreciação dos maus antecedentes e reincidência, nada impede que sejam considerados para demonstrar a personalidade do agente voltada para o crime e sua dedicação às atividades ilícitas.

Nesse sentido:

“PENAL.HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGISTRO DE ATO INFRACIONAL.

INAPLICABILIDADE.ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO.CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DEDIREITO. INVIABILIDADE. FALTA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidencia a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes da Quinta Turma.

4. Concluído pelas instâncias antecedentes que o paciente se dedica ao comércio ilícito de entorpecentes, tendo em vista, além da quantidade e da variedade da droga apreendida (60,50g de maconha e 7,67g de cocaína), o fato de que ao tempo do delito em apreço, ele estava no curso de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos de reclusão, revela-se correta a imposição inicial do regime fechado (mais grave segundo o quantum da sanção

aplicada), tendo em vista a análise desfavorável das circunstâncias judiciais, conforme o art. 33, § 2º, "a", e § 3º, c.c. o art. 59, ambos do CP, e o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do quantum da sanção aplicada (art. 44, I, do Código Penal). 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC 364.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017). GRIFO NOSSO.

No mesmo sentido, decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação - Tráfico de drogas - Recurso Ministerial e Defensivo - Ausência de impugnação no tocante ao mérito - Réu confesso em juízo - Confissão corroborada pelos demais elementos de prova Acusado preso em flagrante delito na posse de 54 gramas de cocaína e 84 gramas de maconha embaladas para o comércio ilícito - Condenação de rigor. Dosimetria - Redução da pena-base ao mínimo legal - Dolo normal à espécie delitiva - Impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão - Afastamento da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 - A prática de atos infracionais em delitos da mesma natureza demonstram a dedicação à atividade criminosa e impedem a concessão da benesse - Inaplicabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos - Benesse que não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime - Mantido o regime fechado. Recurso parcialmente provido para a defesa e provido para o Ministério Público.

(Apelação nº 0003322-24.2013.8.06.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal, Des. Rel. Salles Abreu, Dj. 02.04.14).

Tratando-se de delito assemelhado ao hediondo e tendo-se em conta a necessidade de se individualizar a pena para a adequada prevenção e reprovação, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo os réus iniciar o desconto das penas no regime fechado.

Deverá ser aplicada a causa de aumento de pena porque o réu envolveu o menor na prática delitiva.

Destarte, requer seja julgada procedente a ação penal e o réu condenado nos exatos termos da inicial.

Deverá ser indeferido apelo em liberdade. Estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Lucas Miqueias Marques foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 112-115 e fls. 125-126), no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta de 10h47, na rua das Sapucaias, nº 1, bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Lucas envolveu o adolescente Pablo Luan Bidias Portella em sua conduta criminosa e com ele agindo com unidade de desígnios, trazia consigo 140 porções de "cocaína", 90 porções de "crack" e 29 porções de "maconha", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas. Consta, ainda, que, no dia 25 de fevereiro de 2022, após 10h47, na rua Francisco Maiolino, nº 58, bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca, Lucas guardava e/ou mantinha em depósito 74 porções de cocaína, 52 porções de "crack" e 26 porções de "maconha", destinadas à mercancia ilícita ou entrega de qualquer forma a consumo de terceiras pessoas. Consta, outrossim, que no mesmo dia, após 10h47, na ruados Mognos, n.º 124, Bosques do Lenheiro, nesta cidade e comarca, o infrator Pablo Luan guardava ou tinha em depósito 155 porções de "crack" destinadas à mercancia ilícita, sem autorização.

Ainda de acordo com a inicial, guardas civis passavam pelo local, quando avistaram "três indivíduos em atitude suspeita", ocasião em que um deles (não identificado) entregou uma bolsa para Lucas. Ao perceberem a aproximação, os indivíduos empreenderam fuga, sendo que aquele que entregou a bolsa não foi identificado e logrou evasão. Ato contínuo, durante a fuga o réu entregou ao referido adolescente a bolsa que trazia consigo, o que foi presenciado pelos guardas civis. Feita abordagem, na bolsa entregue pelo réu ao adolescente foram encontradas 140 porções

de "cocaína", 90 porções de "crack" e 29 porções de "maconha", além da quantia de R\$ 82,00. Neste momento, o réu disse ao adolescente: "segure os BO's... É tudo seu", o que foi ouvido pelos guardas civis. Em continuidade, diante do apurado até então, os guardas dirigiram-se às residências do réu e do infrator. Na residência do adolescente Pablo foram encontradas 155 porções de "crack". Por sua vez, na residência do réu foram localizadas mais 74 porções de cocaína, 52 porções de "crack", 26 porções de maconha, uma balança de precisão e rolos plásticos, usados para o embalado de entorpecentes. 0Perante a autoridade policial, o adolescente disse que era responsável pelo tráfico ilícito. Por sua vez, o réu alegou que o responsável era o adolescente e que ele apenas agia como "olheiro".

Interrogado em solo policial, o réu disse que: "na data de hoje, estava no local, juntamente com Pablo, o qual estava vendendo drogas. Estava apenas fazendo a função de 'olheiro'. As drogas e o dinheiro localizados na bolsa pertenciam a Pablo. Na sua residência foi localizada apenas uma balança e dois rolos de papel film. O guarda Miranda acabou agredindo o interrogado batendo com a arma na sua barriga" (fls. 7).

Pablo Luan Bidias Portella contou que: "já tem passagens criminais por receptação. Na data de hoje estava no local em companhia de Lucas. Contudo, era o declarante que estava traficando. Na bolsa tinha aproximadamente 1.400 porções de 'crack', 280 porções de maconha e 1.300 porções de 'óleo' e a quantia aproximada de R\$ 60,00. Tais drogas eram de propriedade do declarante. Os guardas foram a residência dele, onde localizaram outra quantidade de drogas, que estavam escondidas dentro de um sapato atrás do aparelho de tv. Não sofreu nenhuma agressão ou abuso por parte dos guardas civis, contudo, seu amigo Lucas foi agredido" (fls. 6).

Francisco Dernival Miranda Junior, guarda municipal, narrou que: "na data de hoje, estava de serviço com os guardas Willian e Macedo realizando patrulhamento pelo bosque dos lenheiros. Avistaram três indivíduos em atitudes suspeitas, sendo possível observar que um deles levava consigo uma bolsa tipo 'tiracolo' e este entregou algum objeto para o outro rapaz e recebeu algo em troca colocando no interior da referida bolsa, sendo assim resolveram abordá-los. Contudo, um deles percebendo que seriam investigados avisou os demais, o rapaz que momento antes recebeu o objeto deixou o local e foi seguido pelo guarda Macedo, mas acabou não sendo mais localizado. Os outros dois também tentaram fugir do local, porém, foram seguidos pelo declarante e presenciou quando um dos indivíduos entregou a bolsa para o outro e acabou alcançando e abordando este último. O guarda Willian logrou abordar o terceiro indivíduo. Em poder da bolsa, o rapaz abordado pelo declarante foi identificado como sendo o adolescente Pablo Luan Bidias Potella e no interior da citada bolsa foram encontrados 140 porções de cocaína, 90 porções de 'crack', 29 porções de maconha e a quantia de R\$ 82,00. Com o indivíduo abordado pelo guarda Willian, identificado como Lucas Miqueias Marques, nada de ilícito foi encontrado. O adolescente foi conduzido até o local onde estavam Lucas e o guarda Willian e neste momento Lucas se dirigiu para o adolescente dizendo: '... segure os BOS, é tudo seu...'. Dando continuidade nas diligências, se deslocaram até a residência do adolescente Pablo, onde sua mãe autorizou nosso ingresso no imóvel e foram encontradas 155 pedras de 'crack' na sala da residência escondidas dentro de uma bota atrás de um móvel. Também se deslocaram até a residência de Lucas, onde fomos atendidos pelo sr. João Luiz Pereira, avô de Lucas, o qual autorizou a entrada e acompanhou a vistoria. No quarto de Lucas foram localizadas 74 porções de cocaína, 52 pedras de 'crack', 26 porções de maconha, uma balança de precisão e rolos de papel film. O avô de Lucas não acompanhou a ocorrência, pois recebeu uma ligação do hospital e não pode comparecer. Foi dado voz de prisão a Lucas e ambos os autores foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia. [...]" (fls. 3-4).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo guarda municipal Juvenal Estevão de Macedo (fls. 5).

Às fls. 12-14, auto de exibição e apreensão. Às fls. 32-41, laudo de constatação.

Às fls. 100-104 e 153-157, laudo de exame definitivo.

Às fls. 42, juntada certidão de objeto e pé que indica a primariedade do requerido.

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

Com relação à materialidade e autoria, em audiência de instrução foram colhidos os

seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, Francisco Dernival Miranda Junior, guarda municipal. Relatou que viu o réu com adolescente um outro indivíduo. O réu tirou algo de uma bolsa e entregou a esse terceiro indivíduo, recebeu algo em troca e guardou dentro da mesma bolsa. Quando avistaram os guardas, saíram correndo. O terceiro foi para uma direção e foi seguido pelo guarda Macedo, que não conseguiu abordá-lo. O depoente e o adolescente correram para outra direção e o depoente os seguiu. O motorista do carro conseguiu capturar o réu, e o adolescente foi abordado por Miranda. O réu entregou a bolsa ao adolescente e disse que era para ele "segurar os BOs". Foram à casa do adolescente e a mãe dele franqueou a entrada. Encontraram droga na sala, atrás de um móvel, dentro de uma bota. À casa do adolescente foram para apanhar documentação e avisar os responsáveis. Disse que foram à casa de Lucas também para buscar documentação, segundo o guarda. Na casa do réu, entraram com autorização do avô, que teria informado que sabia que o réu traficava. Também localizaram droga ali. As drogas estavam em um quarto que, segundo o avô, era onde Lucas dormia. O avô disse que deixava o seu quarto trancado por medo que o neto colocasse algo ilícito no interior do seu quarto. O avô não foi conduzido à delegacia porque estava de saída para o hospital para comparecer ao hospital onde a esposa estava internada na UTI, onde tinha sido chamado com urgência. Informalmente, o adolescente e Lucas confirmaram que estavam traficando, e o terceiro que fugiu era uma pessoa que estava comprando droga. Quanto à casa que estava nas casas, ambos teriam assumido a propriedade e visavam comercializá-la. De início, o réu não assumiu a traficância e disse ao adolescente para "segurar o BO". Depois, ele assumiu. Nunca tinha visto o adolescente e o réu.

b) Na sequência, ouvido o guarda municipal Juvenal Estevão de Macedo. Trouxe aos autos as mesmas informações do companheiro de farda. Não conhece o réu.

c) Por fim, foi interrogado o réu Lucas Miqueias Marques. No dia 25/2/22, acordou e ficou sabendo que a avó precisava de remédio. Foi ao ponto de drogas para conseguir dinheiro para comprar o remédio. Ficou trabalhando de olheiro. Quando avistou a viatura, gritou aos moleques que estavam traficando. Todos correram. Quem estava vendendo droga era o adolescente Pablo e mais um, de nome Gabriel. A viatura deu a volta e lhe pegou. Fez a abordagem, viu que ele não tinha nada. Ficou esperando o outro guarda. Esse outro guarda apareceu com o adolescente e relatou ter apreendido droga com ele. Quanto à bolsa, estava com o adolescente. Quando o guarda voltou, veio com a bolsa na mão e segurando o adolescente. O réu tinha consigo apenas um Bic e um cigarro. Os guardas foram na casa do adolescente, acharam todo o restante da droga. Foram na sua casa, acharam somente uma balança quebrada no quintal e rolo de plástico. Foi levado à delegacia e lá os guardas falaram que a bolsa era do réu e que tinha passado para o adolescente. Não é verdade que portava droga. Ao aceitar o trabalho de olheiro, sabia que os demais estavam traficando. Ia ganhar R\$100,00/dia pelo trabalho de olheiro. Pablo e Gabriel fariam o pagamento desse trabalho. Pablo e Gabriel estavam no ponto de tráfico todos os dias, mas ele foi ao local somente por necessidade, para comprar medicamento para a avó. Já usou drogas, era viciado em maconha e, de vez em quando, cocaína.

- PRELIMINARMENTE: DA ILICITUDE PROBATÓRIA: INCONSTITUCIONAL E ILEGAL ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Inicialmente, deve ser reconhecida a ilicitude probatória, tendo em vista a atuação inconstitucional e ilegal da Guarda Municipal.

Primeiro, nada de ilícito foi encontrado na posse do réu. Ele apenas estava no local dos fatos perto do adolescente com quem foram localizadas as substâncias entorpecentes, o que, por si só, não é apto a demonstrar envolvimento com a prática delitiva.

Ademais, qualquer continuidade da atuação da GCM depois disso é procedimento investigatório, fora de sua competência, e os achados são prova ilícita - uma vez que decorrentes de atuação da guarda civil fora das suas atribuições. As drogas apreendidas na residência (vistoriada irregular e ilegalmente como será demonstrado abaixo) são assim, provas ilícitas - diretamente ou por derivação.

É o que entendeu recentemente o Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante ocorrido nesta Comarca de Piracicaba:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inexiste óbice à prisão em situação de flagrância, efetivada por guardas municipais ou qualquer outra pessoa, não havendo falar, em tais casos, em ilicitude das provas daí decorrentes.
2. Na hipótese, entretanto, após denúncia anônima, guardas municipais abordaram o réu e, com ele não encontrando entorpecentes, seguiram até terreno localizado nas proximidades, onde foram apreendidos, além de maconha, 10 reais, um filme plástico utilizado para embalar a droga e documento relativo à execução criminal do réu.
3. Desempenhada atividade de investigação, deflagrada mediante denúncia anônima, que desborda da situação de flagrância, deve ser mantido o reconhecimento da invalidade das provas dela decorrentes.
4. Recurso especial improvido. (STJ - 6.^a T - Resp 1.854.065- min. Nefi Cordeiro - j. 02/06/2021 - p. DJe 08/06/2021)

Nos termos da Constituição Federal, art. 144, § 8º, a Guarda Municipal não tem competência para realizar atividade investigativa. É no mesmo sentido a lição doutrinária (GASPARINI, Diógenes; As guardas municipais na constituição federal de 1988, Revista dos Tribunais. set./1991. v.671 p. 46-53; SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição, 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 638-9). Em reforço, não há que se alegar que os guardas municipais teriam atuado legitimamente porquanto, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, seria facultado a qualquer do povo efetuar a prisão em flagrante. In casu, não há que se falar em flagrante porquanto não houve qualquer motivação legítima para proceder à abordagem, eis que, conforme relatado pelas guardas municipais, logo após a visualização do imputado, elas efetuaram a abordagem por considerarem que, ao perceber que seriam abordados, o réu, o adolescente e o terceiro não identificado “empreenderam fuga”. Os guardas sequer visualizaram a prática de qualquer atividade relacionada ao tráfico. O averiguado, portanto, não estava em situação de flagrância.

Além disso atuando como “qualquer do povo”, os guardas municipais podem, única e exclusivamente, efetuar a custódia de algum cidadão que esteja em situação de flagrante (CPP, art. 301), mas não podem efetuar a busca pessoal ou desenvolver atividades tendentes à obtenção de elementos de informação, sob pena de afronta ao disposto no art. 241 c. c/ art. 244, ambos do Código de Processo Penal, eis que, para esses fins, a despeito de estarem encarregados da segurança pública (CF, art. 144), não são considerados “autoridades policiais”. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (STJ, Habeas corpus 545.162/SP, Rel. Nefi Cordeiro, julgado em 4/2/2020).

Assim, tem-se que a apreensão das drogas, no caso sub examine, é elemento de prova ilícito, tendo em vista a inconstitucional atuação da Guarda Municipal. Por esse motivo, o auto de apreensão das drogas deverá ser desentranhado dos autos, eis que é inadmissível o seu ingresso no processo (CF, art. 5º, LVI c. c/ CPP, art. 157). E, por via de consequência, o laudo de constatação, o laudo de exame químico-toxicológico e a prova oral no que se refere à apreensão das drogas são provas ilícitas por derivação, não podendo servir para formação da convicção judicial, pois se mostram incapazes de atestar a materialidade do delito.

Desse modo, a absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPP, é medida que se impõe.

- DA VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Preliminarmente também se deve reconhecer a ilicitude do ingresso dos guardas no imóvel, eis que a entrada no local se deu com violação ao princípio constitucional que assegura a inviolabilidade do domicílio.

Considerada a essencialidade da proteção ao domicílio para a garantia da tranquilidade e bem-estar dos indivíduos, as hipóteses em que agentes do Estado ou mesmo terceiros podem ingressar em habitação alheia sem autorização do morador são limitadas pela Carta Magna às seguintes: a) flagrante delito; b) desastre; c) para prestar socorro; d) por determinação judicial, durante o dia.

Para que não se esvazie o comando contido no artigo 5º, inciso XI, da Carta da República, há de se entender que o flagrante que justifica a invasão de domicílio é

apenas aquele que ocorre em situação de emergência.

Roberto Delmanto Junior, em sua obra "As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração", diferencia com perfeição as situações em que se justifica a relativização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, todas elas baseadas no conceito constitucional de emergência e não de flagrante delitivo de crime permanente, até porque o texto constitucional não se apropria deste conceito penal. Transcrevo: "Sem dúvida, a exceção constitucional à inviolabilidade domiciliar, inclusive em horário noturno e sem determinação judicial, nos casos de flagrante delito, que é disposta ao lado das hipóteses de desastre ou prestação de socorro (art. 5º, XI, 1ª parte) há que ser interpretada sistematicamente, restando patente a intenção do legislador em exigir a configuração de uma verdadeira emergência para que se admita a violação domiciliar, sem determinação judicial, seja ela noturna ou mesmo diurna. Seriam hipóteses, por exemplo, de flagrante de crimes como a extorsão mediante sequestro, em que há necessidade de prestar-se socorro à vítima, que corre perigo de vida etc., o que não se verifica em casos de crimes permanentes como a simples posse de entorpecente ou de armas ilegais. Não havendo esse caráter emergencial, de perigo iminente a um bem jurídico como a vida e a integridade física, a autoridade deverá, sim, obter determinação judicial para invadir o domicílio do suspeito (art. 5º, XI, 2ª parte, da Constituição da República), através da expedição de mandado judicial de busca e apreensão (arts. 240 a 250 do Código de Processo Penal) e não invadir a residência alheia a qualquer hora e sem autorização judicial (o que poderia configurar, inclusive, o crime do art. 150 do Código Penal, dependendo da análise dos incisos I e III de seu §3º, que também devem ser interpretados de acordo com a Magna Carta), sob o pretexto de estar diante de eventual crime permanente, em acusações absolutamente infundadas e, de fato, inexistentes. Por outro lado, justamente para evitar constrangimentos infundados, é que o art. 243 do nosso estatuto processual exige o preenchimento de uma série de pressupostos para a expedição de mandado de busca e apreensão. Poder-se-ia dizer que esse entendimento poderia obstaculizar muito a ação policial; todavia este é um preço pequeno que se paga por vivermos em um Estado liberal e democrático de direito, que sempre deve tomar todas as medidas para restringir, ao máximo, a possibilidade de arbítrios e desmandos das autoridades policiais, por mais bem-intencionadas que possam elas estar." (Obra supracitada, Ed. Renovar, 2ª Edição, 2001, páginas 107/108).

Na hipótese, como não havia perigo iminente a terceiros e nem risco de a prova ser danificada, modificada ou destruída, não havia justificativa razoável para o ingresso forçado na residência, restando claro que a busca realizada pelos guardas foi abusiva e ilegal, sendo inaceitável a prova produzida a partir deste ato.

Conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores, é ônus do Estado comprovar que houve autorização dos moradores para ingresso no domicílio ou que havia justa causa para acesso à residência da acusada sem ordem judicial. Da mesma forma, devem comprovar os fatos que alegam na comprovação das fundadas razões.

Tem-se, assim, que o ingresso na residência do réu se deu em desconformidade com a garantia do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

A esse propósito, deve-se frisar que, não obstante seja permitida a busca pessoal independentemente de mandado judicial (CPP, art. 244), a busca domiciliar somente poderá ser realizada quando o ingresso na residência seja legítimo, isto é, com "[...] o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." (CF, art. 5º, XI). Com efeito, nos termos do art. 241 do Código de Processo Penal, "Quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida da expedição de mandado". Todavia, ainda que tal dispositivo pareça autorizar a busca domiciliar sem a prévia expedição do mandado de busca e apreensão, é certo que não foi ele recepcionado pela atual Constituição Federal, cujo art. 5º, XI, estipula que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

Sendo assim, é inquestionável que houve violação ao domicílio (CF, art. 5º, XI), de

modo que a atuação dos guardas deve ser considerada ilícita.

- DA ADEQUADA CLASSIFICAÇÃO DA CONDOTA

Caso as teses preliminares não sejam acolhidas, é o caso de desclassificação da conduta.

Conforme narrado pelo réu, realmente estava no ponto de venda de entorpecentes e atuando na cadeia do comércio de substâncias ilícitas, mas o fazia na qualidade de "olheiro", ou seja, praticava a conduta prevista no artigo 37 da Lei de Drogas.

Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com o réu. Quanto às demais drogas, estavam com Pablo e na casa do adolescente.

Observa-se que, no caso concreto, eventual sentença de condenação por tráfico estaria embasada apenas nas declarações dos guardas, elementos de prova de reduzido valor, tendo em vista a parcialidade de suas declarações. Nesse contexto, a jurisprudência do TJ-SP e a doutrina são pacíficos em lhes reconhecer o valor probatório, desde que confirmados por outros elementos de prova. Isso porque as declarações deles são tendentes a confirmar a sua própria atuação, motivo pelo qual se impõe cautela na sua apreciação (TJ-SP, 7ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal n. 0373088-52.2010.8.26.0000, Relator Sydnei de Oliveira Jr; TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11). Assim, seria necessário que fossem confirmadas por outros elementos de prova. E tal exigência não significa um demérito à atuação dos policiais; pelo contrário, reconhece-se a importante função que desempenham, mas se pugna que suas palavras sejam apreciadas com cautela, tendo em vista as suas condições e o histórico de violência institucional que caracteriza a polícia brasileira, como, aliás, reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Cosme Rosa Genoveva vs. Brasil.

Isso posto, conclui-se que os elementos de prova disponíveis nestes autos não são suficientes para condenação por tráfico, porquanto não permitem uma conclusão, além de qualquer dúvida razoável, sobre a responsabilidade penal do acusado quanto a esse delito. De rigor, por isso, que a conduta seja desclassificada para a prevista no art. 37 da Lei 11.343/06.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Na remota hipótese de condenação, passa-se a discorrer acerca da pena.

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: o réu é primário e as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, é certo que o acusado é menor de 21 anos, motivo pelo qual faz jus à aplicação da atenuante do artigo 65, inciso I, do CP.

Da mesma forma, a confissão deve ser considerada (art. 65, III, d, CP).

c) Da aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da LD

No presente caso, é possível o reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da LD.

Ora, estão presentes todos os requisitos do referido dispositivo. Conforme jurisprudência pacífica do STF, a quantidade e a natureza das drogas não é circunstância que, por si só, autoriza a denegação de aplicação do referido dispositivo (RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23.5.2017).

Ainda, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível o afastamento do privilégio com base apenas na quantidade ou na qualidade da droga apreendida:

Configura constrangimento ilegal o afastamento do tráfico privilegiado e da redução da fração de diminuição de pena por presunção de que o agente se dedica a atividades criminosas, derivada unicamente da análise da natureza ou da quantidade de drogas apreendidas. (STJ. 5ª Turma. REsp 1.985.297-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 29/03/2022. Informativo 731)

d) Antecedentes infracionais e inexistência de prova de dedicação à atividade criminosa

É certo que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consideram que os antecedentes infracionais não afastam a

possibilidade de incidência do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

Na terceira fase, a i. Magistrada afastou a figura do tráfico privilegiado. Justificou a negativa em razão da dedicação do acusado à prática de atividades criminosas. Embasou sua conclusão no fato de o acusado já ter sido condenado pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas. Impõe-se, contudo, o reconhecimento do privilégio. O envolvimento em atos infracionais não é fundamento legítimo para se extrair a conclusão de alinhamento em atividades criminosas. Isto porque, a resposta estatal para as situações que cercam as crianças e os adolescentes funda-se em premissas diversas, anteriores à imputabilidade penal. Assim, por não configurarem crime ou contravenção penal não parece razoável possam ser consideradas como envolvimento em atividades criminosas a ponto de se afastar a incidência do redutor. Aliás, conforme já decidido por esta Colenda Câmara, a existência no prontuário do réu de apenas um apontamento de ato infracional não revela justificativa idônea para indicar seu envolvimento habitual a atividades criminosas. (TJSP, Apelação n. ° 1500892-95.2020.8.26.0594, 16ª Câmara, r. Des. Marcos Zilli, j. 21/09/2021).

É o caso, portanto, de reconhecimento do privilégio, devendo a pena ser diminuída em seu grau máximo.

e) Do afastamento da majorante do art. 40, VI, da LD

Adicionalmente, é o caso de afastamento da majorante do concurso com adolescentes, porquanto não demonstrado, em juízo, um efetivo liame subjetivo entre o réu e o adolescente, mas apenas a pluralidade de agentes. Da mesma forma, não demonstrado que a conduta do réu corrompeu o adolescente Pablo.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, não aplicável ao caso o regime fechado. Em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime semiaberto. Caso o privilégio seja reconhecido, requer seja fixado regime aberto.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO DE PENA JÁ CUMPRIDO (DETRAÇÃO E ART. 387, § 2º, DO CPP)

Além disso, considerando que o réu respondeu preso ao processo, impõe-se que o tempo de prisão provisória seja declarado como tempo de pena já cumprida, efetuando-se, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, a detração; é o que se extrai do referido dispositivo, assim como da Exposição de Motivos da Lei n. 12.736/2012 e da jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 652.915/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Reconhecido o privilégio, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Isso porque o Senado Federal, no uso da atribuição que lhe confere o art. 52, X, da CF, editou a Resolução n. 05/2012, suspendendo a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A Resolução por conta do julgamento do Habeas Corpus 97.256/RS, em setembro de 2010, ocasião em que o STF, por seis votos a quatro, o STF decidiu que são inconstitucionais dispositivos da Lei n. 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas. Ainda que se discorde da conclusão alcançada pelo STF, o fato é que, com a edição da mencionada Resolução, pelo Senado Federal, restou afastado o fundamento formal-positivo para a proibição de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que suspensa a execução da lei, dotando a decisão do STF, tomada em sede de controle incidental, de efeitos erga omnes. Possível, pois, a aplicação de penas restritivas de direitos, porquanto presentes os requisitos do

art. 44 do CP: a) a pena, ao final aplicada, não será superior a 4 anos; b) o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça; c) o réu não é reincidente em crime doloso; d) a medida mostra-se suficiente, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59.

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. Com efeito, de acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do